农村土地使用权实物交易和地票交易制度评析

——以农村宅基地使用权为中心

○ 周中举

[**摘要**] 为探索统筹城乡综合配套改革，《重庆农村土地交易所管理暂行办法》规定农村宅基地使用权可以实物交易和地票交易的形式进行流转，这是具有突破性的制度创新，对于解决我国农村宅基地空置等低效率使用问题、打破城镇发展普遍遭遇的土地资源瓶颈，具有较强的现实意义。但实物交易和地票交易的交易主体、交易的构成条件、交易方式和程序保障以及利益分配等方面均存在值得商榷和完善之处。现代物权观念已不再过分强调物的所有，而更关注物的利用。对农村宅基地使用权的制度重构，应牢牢把握好用益物权为私权这一逻辑起点，围绕保障权利人利益、实现农村宅基地使用权自由流转的目标来推进。

[**关键词**] 宅基地使用权流转；实物交易；地票交易

[**中图分类号**] F301.1 [**文献标识码**] A [**文章编号**] 1006—012X（2011）—01—0083（05）

[**作者**] 周中举，助理研究员，四川省社会科学院法学研究所（西南政法大学民商法学博士研究生），四川成都 610072

为推进城乡统筹发展，探索农村土地流转新模式，2008年12月1日，重庆农村土地交易所挂牌成立。根据《重庆农村土地交易所管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）规定，农村土地交易所交易品种包括两种。一是实物交易，称之为实盘，包括农村集体土地使用权、农村承包经营权流转和林权交易等；二是指标交易，即地票交易，称之为虚盘。所谓地票，就是农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地，经过复垦成为耕地，并经土地和农业等部门严格验收后形成的地票。这种地票经过农村土地交易所交易后，可以纳入新增建设用地计划，增加等量城镇建设用地。

作为全国首个探索地票交易的要素市场，重庆农村土地交易所被寄予厚望，外界将其与20世纪90年代初期诞生的上海证券交易所之于资本市场的意义相类比。地票交易被认为是最具突破性意义的创新。[1]在这种制度下，土地复垦和用地地票交易基本取代了征地制度，土地从集体所有向国家所有转变的程序大为缩减，建设用地挂钩地票交易实质上是在集体建设用地流转的基础上又往前走了一步。[2]就农村宅基地使用权流转而言，地票交易不仅巧妙地绕开了农村宅基地不能用于非农建设的法律问题，而且通过市场激励机制实现自由交易，它是重庆在深化统筹城乡综合配套改革试验中的一项创新，对于解决我国农村宅基地空置等低效率使用问题、打破城镇发展普遍遭遇的土地资源瓶颈，具有较强的现实意义。[3]

单就农村宅基地使用权流转而言，重庆农村土地流转改革是否真有这么大的价值和意义？笔者认为需要在理论上厘清农村宅基地使用权是否应该自由流转、当前法律应做何完善，并在基础上检视重庆改革实践到底取得多大的进步。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一、证成与证伪：农村宅基地使用权自由流转争议的回顾及个人观点之陈述

关于宅基地使用权流转问题，学界深入的论证主要有禁止流转说、限制流转说和自由流转说等观点。禁止流转说和限制流转说的基本理由是宅基地使用权取得的身份性和不得不承载的社会保障功能以及保护耕地的目的。自由流转说却不赞同。

笔者认为宅基地使用权应自由流转，而反对自由流转论者所关心的问题是可以得到有效解决的。

首先，宅基地使用权自由流转下的耕地保护。依现行法，宅基地使用权有严格的审批程序，其用地数量、申请次数明确，能够从源头上把好耕地用做宅基地的关口。故问题的关键不是宅基地使用权流转能否影响耕地的保护，而是现行的耕地保护法律能否得到有效的执行。

其次，试图禁止或者限制宅基地使用权流转以“保护”农民利益，缺乏行为基础。新中国成立后，城镇居民的住房也是通过福利分配取得，表现为“公房租赁”。住房改革则允许福利性“公房”使用权转让，当初也曾担忧市民将居无定所。但事实证明，市民是“经济人”，住房改革并没有造成其流离失所。农民亦是理性的，不会轻易处分土地，大量历史经验证明了这一点。[4]农民的土地情结到今天也未发生实质性变化，即使农民处分宅基地也符合“经济人”法则。

当然要完全打消宅基地使用权禁止流转论者的顾虑，顺利实现宅基地自由流转，取决于农村社会保障体系的构建与改革。[5]社会保障机制的建立是允许宅基地使用权流转的关键。倘若建立了农民基本生存的社会保障机制，而宅基地使用权又不是社会基本保障机制的一个组成部分或者内容之一，农村宅基地使用权则当然可以自由流转。

其三，关于取得宅基地使用权的身份问题。村民作为集体的一员是无偿取得宅基地使用权的资格，而不应该是反对宅基地使用权自由流转的理由。任何一项财产，无论来源如何，只要在法律上确定归属于某主体，该主体就可以自由地处分它，除非该处分行为有害于社会公共利益，或者设定这项财产权时当事人对其处分作了限制性约定。农村宅基地使用权在设立方面固然有其特性，但一经设立，就成为村民的私权，可以被自由处分，因为其处分对社会公共利益并无损害。世界上不存在“福利分配的东西不得自由处分”这条定律。[6]而且，宅基地使用权流转是将这种福利货币化，不会损害村民的利益。

勿庸讳言，非集体经济组织成员取得宅基地使用权如无期限限制，非本集体成员将永久地占有、使用集体土地，造成所有权与使用权长期割裂的局面。为保护集体经济组织及其成员的利益，笔者认为立法应区分宅基地使用权的取得方式，应明确村民申请是宅基地使用权原始取得的唯一方式，通过继承、赠与、买卖等流转方式取得宅基地使用权的均为继受取得；对不同的取得方式取得的宅基地使用权设定不同的年限要求。原始取得宅基地使用权的不受时间限制，继受取得宅基地使用权的，应受时间限制，但受让人是本集体经济组织成员而且符合申请宅基地使用权的除外。考虑到城市建设用地使用权最长不超过 70年的规定，继受取得宅基地使用权的，从初次流转之日起，最长也不应超过 70年，具体年限应视土地用途而定。

二、模糊与明晰：宅基地使用权流转的法律解释

法律到底有没有禁止农村宅基地使用权流转呢？一种观点认为立法没有绝对禁止农村宅基地使用权流转，仅仅做了限制。[7]另一种观点认为法律、法规明令禁止流转。[8]

从现行规则看，房屋和宅基地使用权是两种不同性质的财产，分属所有权和用益物权客体。所有权人依法对房屋享有占有、使用、收益和处分的权利。土地管理法第 62条第 4款规定“农村村民出卖、出租住房后，再申请宅基地的，不予批准”。显然，此时的宅基地使用权是可以流转的，不然，房屋归买受人，宅基地使用权仍然归出卖人，会导致当事人对土地和房屋权益的使用冲突。结合“地随房走”的原则，该规定应该被认为承认宅基地使用权可以出卖与出租，只是其后不得再申请宅基地。

至于担保法第 37条和物权法第 184条明确规定宅基地使用权禁止抵押，我们认为其根本原因在于，自新中国成立后土地改革运动以来，实现农民居者有其屋，一直是我国农村宅基地使用权制度的唯一价值目标。如果立法允许对宅基地自由流转或设定抵押权，就可能出现农民无住所的情况，于是出现了“房走而地不能动”的矛盾。显然，即使认为法律有禁止宅基地使用权流转的规则，但禁止本身不否定其财产权性质，并不能否认物权的基本属性，更重要的是，禁止的原因是为了保障村民的居住。若真如此的话，并且若有制度保障村民的居住，我们当然会得出如下结论：从立法精神和权利性质来看，宅基地使用权是可以流转的。而担保法和物权法的禁止性规定本身是为了保障村民的居住，而非改变权利性质，禁止流转本身。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、实践与反思：对重庆市有关宅基地使用权流转探索的检视

根据前述之理论探讨和立法需求，下文将围绕实物交易和地票交易的交易主体、交易的构成条件、交易方式及程序保障以及利益分配等方面对《暂行办法》的主要规定进行评析。

（一）关于交易主体

农村宅基地使用权的交易主体有出让人和受让人两方。土地管理法确立了以“户”为基本单位的权利行使主体制度。尽管农民集体成员是宅基地使用权的权利主体，但成员享有的权利必须通过法律规定的权利行使主体才能够实现。在宅基地使用权流转时，也应以户为出让人。根据《暂行办法》规定，在实物交易中农村宅基地使用权出让人为“农户”，而地票交易时出让人为“农村家庭”，二者与“户”有相同的内涵，应无疑义。

但对受让主体，实物交易和地票交易却做了截然不同的规定。[9]宅基地使用权实物交易的受让主体并未突破土地管理法及相关政策法规的既有规定，唯一不同的是增加了高山移民可以跨集体经济组织购买。高山移民是个特殊群体，数量不多，准许跨集体经济组织进行实物交易的根本目的是为了移民脱贫而非让闲置的宅基地有效利用，不具有普适意义。从这个角度看，实物交易落入窠臼，并无实质创新。而值得一提是地票交易，其受让主体扩展到了“一切农村集体经济组织、法人或其他组织以及具有独立民事能力的自然人”等一般的民事主体，使地票交易得以自由进行。那么立法者何以对地票交易与实物交易厚此薄彼？二者区别何在？根据《暂行办法》的相关规定，二者差异在于：一是实物交易的宅基地使用权立法没有年限限制，而地票交易完成后具体指向的土地之使用权则有年限限制；二是地票交易的农户必须提供集体土地使用权证或其他权属证明，以及拥有其他稳定居所和稳定生活来源的书面材料，其本质是农户将宅基地交易后生活有保障，而实物交易对此没有规定；三是地票交易方式为集中竞价交易。毋庸讳言，地票交易大都由房产开发商参与，进行商业开发，管理人（政府）及受让方会有较高的利益期许，会不遗余力的推动。此外，地票交易受厚爱还有一个重要的理由是在当前统筹城乡发展的背景下，各地政府大力倡导土地集约化使用，在实践中集约化就演变成以置换等方式将农村宅基地集中化。以地票的方式将宅基地集中起来整饬，也或多或少的迎合了这一潮流。笔者认为这些差异不是立法对地票交易和实物交易的受让人作不同规定的理由。事实上，地票来源于农户把自己的宅基地复垦，实物交易和地票交易落地后在用地总量上并无实质的不同。宅基地实物交易的年限限制及其他稳定居所和稳定生活来源的书面材料等社会保障问题完全可以通过立法来完善。而在实物交易没有被允许自由流转的情形下，直接规定地票必须进行集中竞价交易，名义上社会所有民事主体均有权参与竞买，看似机会公平，却无实质公平可言。地票交易往往用于商业开发，竞买人大都为房地产开发商，普通民众断无与之竞争的可能，而且每宗交易面积往往较大，也不是普通民众所能购买的。此外，地票交易对出让人而言，宅基地复垦需要一定的准入门槛，而且若宅基地上有房子的还必须拆除，丧失其价值；而对有的买受人而言，购买某一宅基地本身就是喜欢其所处的地理环境，地票交易对其亦毫无意义。而实物交易理应是宅基地流转的常态，是地票交易的基础，地票交易则应是从实物交易派生出的特殊交易形态。《暂行办法》在没有处理好常态的情况下，却以异态推进革新，似有本末倒置之嫌。

笔者认为实物交易的受让人理应扩展为所有的民事主体，同时应依据笔者在前文的论述，对《暂行办法》作如下完善：（1）区分宅基地原始取得与继受取得，明确使用年限，根据土地不同用途最长不超过 70年；农户将宅基地使用权转让后，不能再无偿获得另一块宅基地。（2）继受取得使用年限届满后，地上建筑设施的归属，参照国有建设用地上的相关规定处理。

（二）关于交易构成条件

《暂行办法》第 11条、第 21条分别对实物交易、地票交易的具体条件做了规定。① 二者需要满足的条件大致相同，均包括：一是土地使用权属证明的相关文件；二是出让人拥有

① 参见《重庆农村土地交易所管理暂行办法》，根据其第 11条规定，实物交易须满足如下申让条件：申让方必须提交申让地块土地权利证书或其他权属证明、土地勘测定界报告、土地利用现状图、土地分类面积汇总表、使用年限说明、价款构成及支付要求、交地承诺等有关材料。其中：（一）凡农村集体经济组织申让，必须出具集体土地所有证或其他权属证明，以及拥有该土地的农村集体经济组织三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表同意交易的书面材料；（二）凡农户永久性申让，必须提供集体土地使用证或其他权属证明，以及拥有其他稳定居所和稳定生活来源的书面材料；（三）凡农户或法人申让，均必须提交该土地所在集体经济组织同意交易的书面材料；（四）凡委托申让，必须提交相应授权的法律文书。而根据当前法律规定，农村宅基地使用权的流转只能在同一集体经济组织成员间进行，除了有权属证明外，还应满足上述（二）、（三）项条件。根据其第 21条规定，地票交易须满足农村土地申请复垦的条件：（一）申请农村建设用地复垦，必须提交该土地的权属证明、土地勘测定界报告、土地利用现状图、土地分类面积汇总表；（二）凡农民家庭申请农村宅基地及其附属设施用地复垦，必须提供集体土地使用证或其他权属证明，以及拥有其他稳定住所、稳定生活来源的证明和所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料；（三）凡法人或其他组织申请农村建设用地复垦，必须提交土地所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料；（四）凡农村集体经济组织申请农村建设用地土地复垦，必须出具集体土地所有证或其他权属证明，以及本集体经济组织三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表同意复垦的书面材料。农村宅基地使用权地票交易必须满足上述（一）、（二）项条件。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其他稳定住所、稳定生活来源的证明；三是须经所在农村集体经济组织书面同意。从性质上看，这些条件到底是交易的构成条件呢，还是审批条件？这些条件的设置是否恰当？对此，笔者认为应紧扣宅基地使用权作为用益物权的私权这一特性，在不侵害公共利益的前提下，权利人对权利标的享有处分之自由。宅基地使用权的自由流转应该也必然会是我国农村宅基地使用权改革发展的必由之路。如果任何将宅基地流转形式设计为需要集体经济组织类似于行政许可那样的同意的话，则明显违背权利内涵之自由精神，实无益处。因此，立法中即使设定宅基地使用权流转的交易条件也只是交易本身的构成条件，决不能是类似于行政审批条件。本着这个原则，农村宅基地使用权交易需要提供原来的权利证明，无可厚非。但要求提供“拥有其他稳定住所、稳定生活来源的证明”就值得考虑了。这样规定的根本原因还是在于将农村宅基地视为农民生存保障的根基，担心农民将宅基地转让后，流离失所，成为社会不稳定的因素。事实上，（1）正如前文引证，农民不会丧失理性随意处置安身立命之所，即使有极个别的可能会出现因出售房屋无家可归的情形，那也不宜将万分之一可能性的东西作为普遍立法的取舍标准。[10]（2）该规则以财产的多少作为区分是否成为宅基地使用权的交易主体，实则以财产决定身份，明显违背公平正义之法律要义。有更多财产（其他稳定住所）的人就能成为宅基地使用权的交易主体，反之则不能够。主体财产状况不同导致了宅基地使用权权能不同，有悖物权法理，而且会加剧农村贫富悬殊。因外生制度强化贫富悬殊有失公允。解决问题的根本途径还在于农村医疗、养老、住房等社会保障制度的建立，而不是不顾发展变化了的社会经济文化条件，也不管现实中国农民观念、生活模式和行为选择，强行将其束缚在土地之上。当然，由于农村的社会保障体系还在初步建立之中，其健全和完善还需要一个过程，将“拥有其他稳定住所、稳定生活来源的证明”作为宅基地流转的权宜证明尚可，但绝非长远之计。而农村宅基地使用权交易需要“经所在农村集体经济组织书面同意”就断然不可了。这是因为：一是不管哪种交易并未改变集体土地所有权的归属，不会危害集体经济组织的利益；二是交易只是宅基地用益物权的行使，不会影响集体经济组织的管理，也不需要集体经济组织的同意；三是集体经济组织只要保证在分配宅基地时是公平的，集体经济组织的成员都有将宅基地使用权用于交易的机会，该机会是均等的；四是如果纯粹的私法行为介入了类似于行政权利的干预，该制度绩效会产生明显的负效应。因此，在农村宅基地使用权交易中不需要农村集体经济组织“同意”，但为了管理的需要出让农户应履行告知义务，比如，将自家的宅基地复垦为耕地后，应告知集体经济组织，便于其重新发包出去。

（三）关于流转的具体方式及程序保障

《暂行办法》第9条第4款规定的宅基地使用权实物流转的主要方式有：出租、转让、转租、入股、联营等。① 由于流转方式多种，每一种流转方式又有多样具体的运转模式，《暂行办法》没有也不可能对各种流转方式作具体明确的规定，因为这些问题本来就该交给市场自行处理。而基于法律的禁止性规定，《暂行办法》并没有将“抵押”这一重要的流转方式规定其中。因此，《暂行办法》规定的实物流转方式更多的只具有宣示效应，没有实质的意义，问题的根本还在于解决宅基地使用权自由流转。

《暂行办法》明确规定地票交易必须在农村土地交易所内以公开竞买的方式进行。地票交易往往涉及商业化操作，交易标的较大，类似于以招拍挂的方式来出让国有土地使用权，需要规定交易场所和交易方式，注重农村宅基地使用权自由流转的程序保障。这具有以下价值：一是实现充分竞争，以市场的手段来合理有效的配置资源；二是有利于实现宅基地使用权的市场价值的最大化，保护农户的利益；三是在指定地点公开竞买的方式利于各方监督和管理，以程序正义保障地票交易的实质正义。实物交易则更多类似于城市房屋的一般出卖行为，为物权处分行为，由买卖双方自由协商即可，而不必要求在指定地点以特定的方式加以处分。

另外，针对我国宅基地使用权权属关系复杂的历史和现实，应建立和完善农村宅基地使用权的登记公示制度。登记作为不动产物权公示的法定方式，具有公信的效能。建立和完善宅基地使用权的初次登记制度，明确权属；建立宅基地使用权流转备案审查制度，不论是实物交易还是地票交易，在宅基地使用权流转前，需进行权属审查公示，通知所在地

① 根据各地宅基地使用权流转实践，这些流转形式具体内涵为：（1）出租，是指农村宅基地使用权人将宅基地使用权出租给承租人，承租人支付租金的行为。（2）转让，是指农村宅基地使用权人通过买卖、赠与或以其他合法方式将宅基地使用权转移给他人的行为，其实质是宅基地使用权的转移。（3）转租，是指农村宅基地使用权承租人将宅基地使用权向后手再次出租的行为，其本质仍是宅基地使用权的租赁关系。（4）入股，是指依约定在一定年限内将宅基地使用权作价与其他出资人合作开发，并分享收益的行为。（5）联营，是指依约定在一定年限内将宅基地使用权作价与其他出资人联合从事非农业生产经营活动，并分享收益的行为。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

农村集体经济组织并在当地进行公示，异议人须在规定的时间提出异议，以保障各方权利人权益，维护流转秩序；宅基地使用权流转后，应立即办理变更登记手续。

(四)关于流转收益的分配

《暂行办法》对宅基地使用权实物交易方式获得收益的分配未作规定，出让人作为物权处分人理应获取其交易价值，实属正常，现实生活中也是归出让的农户所有应无疑义。可令人费解的是《暂行办法》第 31条分配权益保障第 2款规定“农村宅基地使用权交易收益，原则上大部分归农民家庭所有，小部分归农村集体经济组织所有，具体分配比例由农民家庭和农村集体经济组织协商确定”。

笔者认为将地票交易收益由农民家庭和农村集体经济组织按比例分配毫无道理。集体作为所有权人基于集体经济组织成员身份，在设定宅基地使用权并归集体成员享有时需要公平公正，此用益物权一旦设定即归农村家庭各自平等享有。地票交易实则为用益物权人处分其用益物权，将集体平等赋予集体成员的权益货币化。而作为宅基地所有权人的集体，如果其参与地票交易收益分配的话，其依据何在？这无异于集体只对该用益物权货币化集体成员的部分收益据为己有，而没有交易的集体成员却不向集体缴纳相应的份额，这显然不合理。而且，在我国城市化日益推进的今天，各地农村集体经济空壳化日益明显，大量提取一笔集体财产出来如何有效管理和使用必将是个难题。此外，我国农村土地承包法允许农民土地承包经营权依法流转，收益归农户所有。该《暂行办法》也在同一条第 1款规定“耕地、林地等承包经营权交易收益，归农民家庭所有”。为何同为农村土地用益物权的流转却规定不同的收益分配政策？如果农村集体参与宅基地使用权流转收益分配，那么这个比例是多少？确定依据是什么？这个比例个案协商还是全市统一规范？这一系列的基本问题均未明确，实践中根本难以操作。

笔者认为，在全民社保的背景下，应将宅基地使用权自由流转同城乡统筹结合起来，在国家主导下建立统一的农民社会保障体系，将宅基地使用权初次流转的所得资金提取一定比例，用于建立失业保险金和农民廉租住房保障金等社保制度。设立专门机构，专款专用，为宅基地使用权流转后，为没有居所且收入低于当地最低生活保障的农民提供廉租房租金和生活补助。

四、结语

建立在人口不流动的自然经济假设基础之上，限制农村宅基地使用权自由流转制度，已不适应我国社会主义市场经济发展的要求。现代物权观念已不再过分强调物的所有，而更关注物的利用。对宅基地使用权的制度重构，应牢牢把握好用益物权为私权这一逻辑起点，围绕保障权利人利益、实现农村宅基地使用权自由流转的目标来推进。

参考文献：

[1]中国农村土地交易第一步 [N]. 重庆日报，2009－4－29.

[2]陈 沅. 农村土地流转中交易客体的界定 [N]. 产权导刊，2009－4－16.

[3]王守军，杨洪明. 农村宅基地使用权地票交易分析 [J]. 财经科学，2009，(04)：95－96.

[4]袁 铖. 城乡统筹发展背景下农村宅基地使用权流转问题 [J]. 贵州财经学院学报，2009，(01)：91.

[5]傅鼎生. 集体土地使用权流转之争——中国物权立法热点问题研究综述 [EB/OL]. http：www. sls org cn，2007－5－25.

[6]李建华，杨代雄. 我国土地用益物权体系的立法构造 [J]. 当代法学，2004，(01)：109.

[7]陈业龙. 论农村宅基地使用权的流转 [J]. 湖南公安高等专科学校学报，2008，(03)：11.

[8]陈金田. 关于我国农村宅基地使用权流转问题的若干思考 [J]. 延安大学学报 (社会科学版)，2008，(02)：64.

[9]重庆农村土地交易所管理暂行办法 [Z]. 第 12条第 2款、第 24条第 5款.

[10]刘 俊. 农村宅基地使用权制度研究 [J]. 西南民族大学学报 (人文社科版)，2007，(03)：121.

责任编辑：王丽娟

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net